

1529013-33.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena. O réu é tecnicamente primário, de acordo com a certidão de fls. 41/42. No entanto, possui maus antecedentes criminais atestados nos autos, posto que condenado definitivamente pelo delito de tráfico de drogas perante a 17ª Vara Criminal do Foro Central (autos nº 0102392-48.2012.8.26.0050).

Neste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529013-33.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529013-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE VIANA NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE VIANA NOGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 8h55min, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, nesta cidade de São Paulo, guardava drogas, para fins de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 21 invólucros contendo maconha (Tetra-hidrocanabinol), 04 invólucros de cocaína e 18 frascos de lança-perfume (Tricloroetileno).

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, e apresentou resposta à acusação.

Juntou-se aos autos o laudo pericial de fls. 124/126.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público buscou a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, nos termos do art 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo; pelo não reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; pela aplicação do redutor previsto no art 33, §4º da Lei 11.343/06; bem como pela fixação de regime aberto ou semiaberto para início do cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é

positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão das drogas, laudo de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico toxicológico positivo para cocaína, maconha e lança perfume, relatório final da autoridade policial, bem como pela robusta prova produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto a autoria, também não há que se falar em dúvida quanto a versão apresentada pelos policiais. Isso porque os dois policiais ouvidos em audiência de instrução apresentaram versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos.

Com efeito, o policial militar FELIPE DE PALMA MEDEIROS, ouvido em juízo, após prestar o compromisso de dizer a verdade, narrou que estava em patrulhamento pela região central de São Paulo, conhecida pelo tráfico de drogas, na companhia de seu parceiro e avistaram o réu com uma sacola preta nas mãos que ao perceber a presença policial, dispensou a sacola ao chão e tentou se evadir do local.

Após breve perseguição o réu foi abordado e em busca pessoal, localizaram uma quantia em dinheiro, um celular e um papel com anotações do tráfico de drogas. A sacola foi recuperada e dentro dela foram localizadas porções de maconha, frascos de lança-perfume e algumas porções de cocaína.

Afirmou que a distância em que visualizaram o acusado, antes da abordagem, era de no máximo 10 metros. Ademais, afirmou que na região há muitos transeunte, mas o acusado se encontrava sozinho naquele momento e não chegaram a fazer campana no local. Alegou, ainda, que ao ser indagado a respeito dos entorpecentes o réu confessou o tráfico.

No mesmo sentido, o policial militar GIOVANE DE SOUZA DA SILVA, ouvido em juízo, declarou que estava juntamente com seu colega de farda, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando viram o acusado de frente a uma barraca de lona, trazendo consigo uma sacola preta nas mãos.

Confirmou, ainda, que o réu, ao perceber a presença policial, dispensou ao chão uma sacola preta e tentou fugir e diante disso foram a seu encalço e conseguiram abordá-lo. A sacola foi localizada e apreendida e dentro dela havia vários entorpecentes. Já com o acusado foram apreendidos um papel com contabilidade do tráfico e cerca de R\$ 100,00 em dinheiro. Questionado, o réu informou à equipe policial que, por conta da dificuldade financeira em que se encontrava, estava traficando no local. No mais, informou que a abordagem ocorreu de imediato, após visualizarem a atitude suspeita do réu e que não houve campana ou apreensão outras pessoas.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que trabalha com reciclagem e, na data dos fatos, estava em frente a um mercado aguardando uma funcionária que lhe entregaria papelões. Informou que viu os policiais abordarem dois rapazes na parte superior da praça. Após recolher o material para reciclagem, seguiu em direção aos policiais e também acabou sendo abordado por eles. Informou aos policiais que estaria no local fazendo reciclagem. Negou a versão apresentada na delegacia, disse que apenas assinou o papel sem ser ouvido. Ademais, não soube esclarecer a razão dos policiais não terem levado à delegacia os dois rapazes que estavam sendo abordados anteriormente. Declarou que, ao contrário do que consta no interrogatório policial, está em situação de rua há dois anos e não faz uso de drogas. Por fim, afirmou que conhece os policiais de abordagem anterior, na qual ele e os demais carroceiros que ali estavam foram ofendidos e ameaçados, mas naquela ocasião não chegou a ser preso.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

Isso porque, suas declarações do réu em juízo não vieram corroboradas por outras provas e não são dignas de crédito. Isso porque, as alegações de que os policiais já o tinham abordado anteriormente e haviam prometido mal maior caso os encontrasse novamente é pueril e inacreditável, ainda mais diante de seu interrogatório de fls. 09, colhido na presença de uma autoridade policial e de um escrivão de policial, em

que confirma a narrativa dos policiais na fase policial e em juízo, alegando que realmente estava no local vendendo as drogas consigo encontradas.

E neste ponto, embora em juízo os policiais tenham dito que com o réu havia anotações de tráfico de drogas, veja-se que tal fato não foi narrado em seus depoimentos policiais deixando claro que não houve apreensão.

Esta divergência, contudo, é aceitável e em nada macula seus depoimentos, notadamente em razão do tempo transcorrido e dos inúmeros flagrantes que são diariamente conduzidos por esses policiais.

Observa-se, ademais, que a quantidade e a variedade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e o local onde o réu estava, reconhecido como sendo ponto onde são comercializados entorpecentes diariamente, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Ademais, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não havendo nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário, de acordo com a certidão de fls. 41/42. No entanto, possui maus antecedentes criminais atestados nos autos, posto que condenado definitivamente pelo delito de tráfico de drogas perante a 17ª Vara Criminal do Foro Central (autos nº 0102392-48.2012.8.26.0050).

Neste ponto, não há que se falar em desconsideração desta condenação apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado ela não pode mais ser considerada como agravante em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-la como maus antecedentes, já que demonstra a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos

Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Tal fato, aliado a variedade de entorpecentes apreendidos (conforme auto de apreensão de fls. 14), demonstram que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, permitindo-se aumentar a pena base em 1/6, que chega ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão; e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal deve ser reconhecida já que o crime ocorreu durante o estado de calamidade pública da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879/2020), mormente no caso dos autos, em que o réu, violando recomendações das autoridades sanitárias, fato este que possibilitou o avanço de mais uma variante a “Ômicron” que causou, em pouco tempo morte de várias pessoas.

É certo que a lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida, sendo possível concluir que o legislador entendeu que o cometimento de delitos nas ocasiões excepcionais previstas demonstra o absoluto desprezo e insensibilidade do autor do fato à sociedade, já gravemente vulnerabilizada afetada em termos de saúde, economia, trabalho e perdas pessoais) pandemia e a seus valores, o que dota a conduta criminosa de um grau mais acentuado de reprovabilidade, justificando, portanto, o agravamento da pena, em mais 1/6, chegando-se a 6 anos, 9 meses e 20 dias, de reclusão e 12 dias-multa.

Neste sentido:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se

valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Autos nº 1509419-67.2020 : "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

"Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhas postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime" (Cleber Masson, Direito Penal vol. 1, ed. Método, 10ª ed).

Na terceira fase da dosimetria, mostra-se incabível o reconhecimento do redutor

previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que após cumprir pena por tráfico de entorpecentes mais uma vez o acusado foi preso em flagrante delito, trazendo consigo para venda, várias substâncias entorpecentes, o que demonstra que continua se dedicando a atividades ilícitas, e que portanto não faz jus ao benefício legal. Por fim, considerando, que não há nos autos provas da condição financeira do acusado, o dia multa será fixado no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, por estar incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, e ainda em razão de seus maus antecedentes decorrente de condenação pelo mesmo delito, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Outrossim, levando-se em conta a quantidade de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal. Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Determino ainda, se o caso, destruição de toda droga apreendida, inclusive eventual quantia guardada para contraprova, nos termos legais.

Por fim, declaro a perda dos valores e bens apreendidos em favor da União nos termos do art. 63, da Lei de Tóxicos.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA